刑法11 筆記：不能未遂

> 來源：刑法11 課程字幕 01:41:00 ~ 02:35:59

🕮 法條原文速查

> **§26**（不能未遂）
> 行為**不能發生犯罪之結果**，又**無危險**者，**不罰**。
> → 兩要件缺一不可：(1) 不能發生犯罪結果 + (2) 無危險

> **§25 II**（普通未遂效果）
> 未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之。
> → 普通未遂 = 得減；不能未遂 = **不罰**

> **§23**（正當防衛）
> 對於現在不法之**侵害**…→ 不能未遂無法益危險 → 不構成「侵害」→ 不能對不能未遂主張正當防衛

📋 學者見解速查

> **蔡聖偉老師**（碩論主題即為不能未遂；文章〈惡視力〉）：
>
> - 不能未遂之所以無罪，與不法、罪責無關
> - 是基於**刑事政策考量**，放在**三階外面**（事理上阻卻刑罰事由）
> - 理由：不罰不能未遂不會破壞行為規範效力（無人模仿）

> **甘添貴老師等（台灣刑事法學會）**：
>
> - 2006年修法主導者，採**客觀未遂論**
> - 不能未遂無危險→不罰（客觀未遂論的必然結論）

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「§26不能未遂的兩大要件？」	(1) **不能發生犯罪結果** + (2) **無危險** → 兩者缺一不可
「不能未遂的效果？」	**不罰**（無罪）。2006年修法前有罪，修法後改為不罰
「不能發生犯罪結果的三種類型？」	**主體不能**、**客體不能**、**手段不能**
「如何判斷無危險？三說為何？」	**客觀危險說**（事後判斷）、**具體危險說**（理性旁觀者）、**重大無知說**（日常生活知識）
「具體危險說與重大無知說何時結論不同？」	行為人**誤認容器內裝物**（如以為胃腸藥是毒藥）→ 具體危險說：無危險（旁觀者看到是胃腸藥）；重大無知說：有危險（搞錯內容物非重大無知）
「不能未遂放在三階論何處？」	A. 構成要件（不能未遂無著手）vs. B. **三階外面**（事理上阻卻刑罰事由，通說）
「不能未遂體系定位的區別實益？」	主要在**共犯**：放構成要件→正犯不該當→共犯不成立；放三階外→正犯該當違法有責→共犯可能成立
「可否對不能未遂正當防衛？」	**不可**。不論體系定位如何，不能未遂無法益危險→不構成「侵害」
「迷信犯是什麼？」	不具規範意義的現象描述。有故意→不能未遂（手段不能）→無危險→不罰

正文

一、不能未遂概說

定義

犯罪之所以無法既遂，自始就不可能實現，換作任何人都不能。

與普通未遂的比較

比較	普通未遂	不能未遂
無法既遂原因	偶然因素	**自始不可能**
效果	**得減**（§25 II）	**不罰**（§26）
修法前效果	得減	有罪（2006年改為不罰）

歷史演變

- 2006年修法前：不能未遂有罪
- 2006年修法後：改為**不罰**
- 修法背景：由甘添貴老師主導的台灣刑事法學會，採客觀未遂論 → 不能未遂無危險→不罰

二、要件一：不能發生犯罪結果

> 此要件**篩選意義不大**（幾乎所有未遂都套得出「不能發生結果」），但法條有規定仍須審查。

三種類型

類型	定義	案例
主體不能	行為人因**誤認事實**而以為自己是犯罪主體	業務經理被開除（不知情），仍代表公司簽約→背信未遂（主體不能）
客體不能	行為客體不存在	屍體以為是活人而開槍；持槍掃射但被害人不在家
手段不能	手段客觀上無法遂行犯罪	槍枝射程不夠；毒藥劑量不足；彈弓射民航機

主體不能的精確定義

> **關鍵**：主體不能限於**事實誤認**，非法律評價誤認

案例	是否主體不能	理由
經理被開除不知情，仍代公司簽約	**是**	未意識到「被開除」事實 → **事實誤認**
保全以為自己是公務員而收賄	**否**	保全是否為公務員 → **法律評價**問題，非事實誤認

三、要件二：無危險（核心判斷要件）

> 此為不能未遂的**判斷關鍵**。所有未遂幾乎都滿足要件一，但要件二才真正區分普通未遂與不能未遂。

三說比較

學說	視角	判斷標準	現況
客觀危險說	**事後**（上帝視角）	自始不能＝無危險；偶然因素＝有危險	歷史說法，幾乎無人採
具體危險說（新客觀說）	**行為時**（理性旁觀者）	一般旁觀者是否覺得有危險	通說之一
重大無知說	**行為人認知**	出於日常生活知識的**重大無知**才無危險	留日老師採

（一）客觀危險說的問題

- 從事後（上帝視角）判斷 → 什麼都知道 → 幾乎所有未遂都「無危險」
- 比喻：恐怖片第一次看很恐怖，第二次看（已知劇情）完全不恐怖 → 事後判斷失去意義
- 結論：若貫徹此說 → 絕大多數普通未遂都變成不能未遂 → 不合理

（二）具體危險說（新客觀說）

- 危險 ≠ 事實，危險 = **價值判斷**（感受）
- 判斷者：**理性旁觀者**（一般第三人），以行為時的角度判斷
- 專業領域：旁觀者需具備**該領域專門知識**
    - 製毒案：旁觀者需懂化學方法
    - 販毒案：不需要專業（一般人即可判斷）

（三）重大無知說

- 只有出於對**日常生活知識**的重大無知 → 才算無危險
- 白話：一般人聽了會覺得「這人是不是智商有問題？」→ 才算重大無知

重大無知案例	非重大無知案例
用**彈弓**射民航機	誤算槍枝射程
用**菊花茶**讓孕婦流產	算錯毒品提煉方式
用**全糖飲料**毒殺糖尿病患	算錯毒藥劑量
拿**田徑裁判槍**（鞭炮槍）殺人	誤拿胃腸藥當毒藥

三說在具體案例的比較

案例	客觀危險說	具體危險說	重大無知說
被害人已死，丙不知而持刀刺之	無危險	**有**危險（旁觀者不知死亡）	**有**危險（非重大無知）
搶警察配槍射擊，但槍未裝子彈	無危險	**有**危險	**有**危險
誤以為胃腸藥是毒藥，拿去給被害人吃	無危險	**無**危險（旁觀者看到是胃腸藥）	**有**危險（搞錯容器內容物非重大無知）

> ⚠ 上方第三例是**具體危險說與重大無知說結論相異**的少數案例

四、迷信犯

定義

行為人想透過自然科學無法驗證的方式實現犯罪（如扎稻草人、唸咒。

分析步驟

```
迷信犯行為
      ↓
1. 有無故意？
   ├── 無（單純願望）→ 不成立犯罪（無故意）
   └── 有（確信可實現）→ 進入不能未遂分析
                              ↓
2. 不能發生犯罪結果？→ 是（手段不能）
                              ↓
3. 無危險？→ 是（任何學說皆認為無危險）
                              ↓
4. 結論：不能未遂→不罰（§26）
```

> **結論**：迷信犯不具規範意義，只是一種嚴重的不能未遂的現象描述。考試不需特別論迷信犯，直接用不能未遂分析即可。

五、不能未遂的體系定位

兩說

定位	構成要件（紅色線）	三階外（黃色線）
主張者	留日老師為主	**蔡聖偉老師**（通說）
代表說法	不能未遂**無著手**（採客觀著手理論）	**事理上阻卻刑罰事由**
不法？	構成要件**不該當**	該當、違法、有責 → 但三階外不罰
理由	客觀上根本找不到著手時點	不罰是基於**刑事政策**：不會破壞行為規範效力

蔡聖偉老師的論證

```
為什麼罰未遂犯？→ 維護行為規範效力
      ↓
如果不罰不能未遂 → 有人會模仿嗎？
      ↓
不會（彈弓射飛機、全糖殺糖尿病患→沒人想模仿）
      ↓
不罰不能未遂 → 不影響行為規範效力
      ↓
結論：基於刑事政策，放棄刑罰（三階外面）
```

六、區別實益：共犯

主要區別實益：教唆/幫助不能未遂行為，能否成立共犯？

> 共犯從屬性：成立教唆犯、幫助犯→正犯必須**該當且違法**

體系定位	正犯狀態	共犯能否成立
構成要件（紅色）	構成要件**不該當**	**不能**成立共犯
三階外（黃色）	該當＋違法＋有責（僅三階外不罰）	**可能**成立共犯

案例：扎稻草人＋神壇師傅

事實

1. 甲確信扎稻草人可殺人（有故意）
2. 甲向神壇師傅講述計畫並索取稻草人
3. 師傅提供十個稻草人給甲
4. 甲回去狂扎

分析

體系定位	甲（正犯）	師傅（幫助犯）
放構成要件	不該當（無著手）→ 無罪	共犯從屬性不成立 → **無罪**
放三階外	該當＋違法＋有責（三階外不罰）→ 無罪	共犯從屬性成立 → **可能有罪**

七、正當防衛的問題

- **結論**（現在主流見解）：**不能**對不能未遂正當防衛
- 不論體系定位如何：

體系定位	能否正當防衛	理由
放構成要件	不能	連不法都沒有
放三階外	一樣**不能**	雖有不法，但對法益**無危險** → 不構成「侵害」

> 正當防衛要件：現在不法**侵害**。不能未遂雖可能不法，但不構成「侵害」→ 一律不得正當防衛。

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§26	不能未遂	本筆記核心
§25	未遂犯	普通未遂 vs. 不能未遂
§23	正當防衛	不能對不能未遂正當防衛

關鍵學者見解速查表

學者	見解
蔡聖偉	不能未遂放三階外面（事理上阻卻刑罰事由）；認為不罰是因不影響行為規範效力
甘添貴	採客觀未遂論→不能未遂無危險→不罰；2006年修法主導
許澤天	具體危險說中，專業領域須用具專業知識的旁觀者